

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、Aを川の中に突き落として溺死させようと思い、橋の側端に立っていたAを突き飛ばしたところ、Aは落下する途中で橋脚に頭部を強打して即死した。甲には殺人既遂罪が成立する。
2. 甲は、乙に対し、Aを殺害するよう唆したところ、乙は、その旨決意し、夜道で待ち伏せした上、歩いてきた男をAだと思って包丁で刺し殺したが、実際には、その男はBであった。甲には殺人既遂罪の教唆犯が成立する。
3. 甲は、隣人Aの居宅の玄関前に置いてあった自転車を、Aの所有物と認識して持ち去ったが、実際には、同自転車は無主物だった。甲には遺失物等横領罪が成立する。
4. 甲は、駐車場に駐車中のA所有の自動車を見て、Aに対する腹いせに傷つけてやろうと思って石を投げたが、狙いがそれて、その隣に駐車中のB所有の自動車に石が当たってフロントガラスが割れた。甲には器物損壊罪が成立する。
5. 甲は、乙との間で、Aに暴行を加えることを共謀したところ、乙は、Aに対して暴行を加えている最中に興奮のあまり殺意を生じ、Aを殺害してしまった。甲には傷害罪の共同正犯が成立するにとどまる。

1 正しい

大判大 12.4.30 (百選 I 15 事件)。本記述では、侵害に至る因果経過に錯誤があるため、生じた構成要件該当事実について故意を認めることができるかが問題となる。判例は、殺意を持って被害者の首を絞めたところ被害者がぐったりしたため死んだと思い込んだ被告人が、犯行の発覚を防ぐ目的で砂浜に被害者を捨てたが、被害者は実はまだ生きており、首を絞められたことと砂末を吸い込んだことにより死亡したという因果関係の錯誤が問題となった事案において、被告人の行為と被害者の死亡との間には因果関係が認められるとしている。そして、本判決は、因果関係の有無だけを問題として殺人罪の成立を肯定しているのであるが、結論としては、因果関係の錯誤は故意を阻却しないと立場を黙示的に採ったと解されている。本記述では、Aを川の中に突き落として溺死させようと思い、橋の側端に立っていたAを突き飛ばしたところ、Aは落下する途中で橋脚に頭部を強打して即死したという因果関係の錯誤が認められるが、かかる錯誤は故意を阻却しないことになるため、甲には殺人既遂罪が成立する。

2 正しい

最判昭 53.7.28 (百選 I 42 事件)。本記述では、正犯である乙に客体の錯誤があるため、共犯である甲にとっては方法の錯誤があることになる。そこで、方法の錯誤の場合に故意が阻却されるかが問題となる。判例は、強盗犯人が殺意をもって被害者に暴行を加えたところ、被害者を殺害するに至らず、傷害を負わせたにとどまり、他方で、その予期しなかった第三者に対しても傷害の結果を生ぜしめた事案において、「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りるものと解すべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、構成要件に該当する事実を認識していれば規範の問題に直面することを挙げている。本記述では、AとBとは殺人罪の構成要件である「人」の範囲で符合しているから、かかる錯誤は甲の故意を阻却しない。よって、甲には殺人既遂罪の教唆犯が成立する。

3 誤っている

本記述では、無主物が遺失物等横領罪の客体となるかが問題となる。遺失物等横領罪の客体は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」であることが必要であり、無主物は客体とはなり得ない。本記述では、自転車は無主物である以上遺失物等横領罪の構成要件には該当せず、甲がAの所有物と認識していたとしても、窃盗罪も遺失物等横領罪も成立しない。

4 正しい

最判昭 53.7.28 (百選 I 42 事件)。本記述では、A所有の自動車を狙って隣に駐車中のBの自動車のフロントガラスを割っているので、方法の錯誤がある。そこで、方法の錯誤がある場合、故意が阻却されるかが問題となる。肢2で述べたとおり、方法の錯誤があっても、構成要件の範囲で重なり合いが認められる限り、故意は阻却されない。本記述では、A所有の自動車とB所有の自動車は、器物損壊罪の構成要件の「他人の物」の範囲内で重なり合いが認められ、器物損壊罪の故意は阻却されないことになるので、甲には器物損壊罪が成立する。

5 誤っている

最決昭54.4.13(百選I92事件)。本記述では、Aに暴行を加えることを共謀したにとどまり、Aの殺害を共謀していないため、殺意のなかった甲にいかなる範囲で乙との共同正犯を認めるべきかが問題となる。判例は、傷害を共謀したところ、そのうちの1人が殺意をもって犯行を行った場合について、殺意のなかった者にいかなる犯罪が成立するかが問題となった事案において、「殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから、暴行・傷害を共謀した被告人Xら7名のうちのYが……派出所前でH巡査に対し未必の故意をもって殺人罪を犯した本件において、殺意のなかった被告人Xら6名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである。すなわち、Yが殺人罪を犯したということは、被告人Xら6名にとっても暴行・傷害の共謀に起因して客観的には殺人罪の共同正犯にあたる事実が実現されたことにはなるが、そうであるからといって、被告人Xら6名には殺人罪という重い罪の共同正犯の意思はなかったのであるから、被告人Xら6名に殺人罪の共同正犯が成立するいわれはなく、もし犯罪としては重い殺人罪の共同正犯が成立し刑のみを暴行罪ないし傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪の共同正犯の刑で処断するにとどめるとするならば、それは誤りといわなければならない。」としている。本記述では、甲はAに暴行を加えることを共謀したにとどまるが、乙が殺意をもってAを殺害した以上、殺意のなかった甲には、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立することになる。